



계약, 그 이상의 약속: 공정한 사회를 위한 가족법의 새로운 길

약혼, 혼인, 그리고 공동양육권에 대한
고찰

약혼, 혼인, 그리고 공동양육권에 대한 고찰

첫 약속: 약혼 계약의 법적 성립

정의 (Definition)

장차 혼인할 것을 약속하는 계약.

성립 (Formation)

특별한 방식이 필요 없으며, 당사자 사이의 합의만으로 성립.
(대법원 1998.12.8. 선고 98므961)

자격 (Qualification)

- 성년자는 자유롭게 약혼 가능 (민법 제800조).
- 미성년자는 만 18세가 되어야 하며, 부모나 후견인의 동의 필요 (민법 제801조).



약속의 무게: 약혼의 법적 효과와 해제

의무와 한계 (Duty and Limitation)

약혼은 혼인을 강제로 이행시킬 수 없으나(민법 제803조),
정당한 사유 없는 파기 시 손해배상 책임이 발생.

제3자 침해 (Third-party Infringement)

제3자가 약혼 관계를 침해하여 혼인이 불가능하게 된 경우,
불법행위에 기한 손해배상 청구 가능.

약혼 해제 사유 (Grounds for Termination)

민법 제804조에 명시된 정당한 해제 사유가 있을 경우,
일방적으로 약혼을 해제하고 예물 반환을 청구할 수 있음.

- 자격정지 이상 형 선고
- 성년후견 개시
- 불치의 병
- 다른 사람과 약혼/혼인/간음
- 1년 이상 생사불명 등



법적 결합: 혼인 계약의 본질과 요건

본질 (Essence)

정신적·육체적으로 결합하여 생활 공동체를 형성하려는 의사의 합치.
(일시적 비동거는 무관하나, 동거하지 않을 것을 조건으로 하는 혼인은 무효)

형식적 요건 (Formal Requirement)

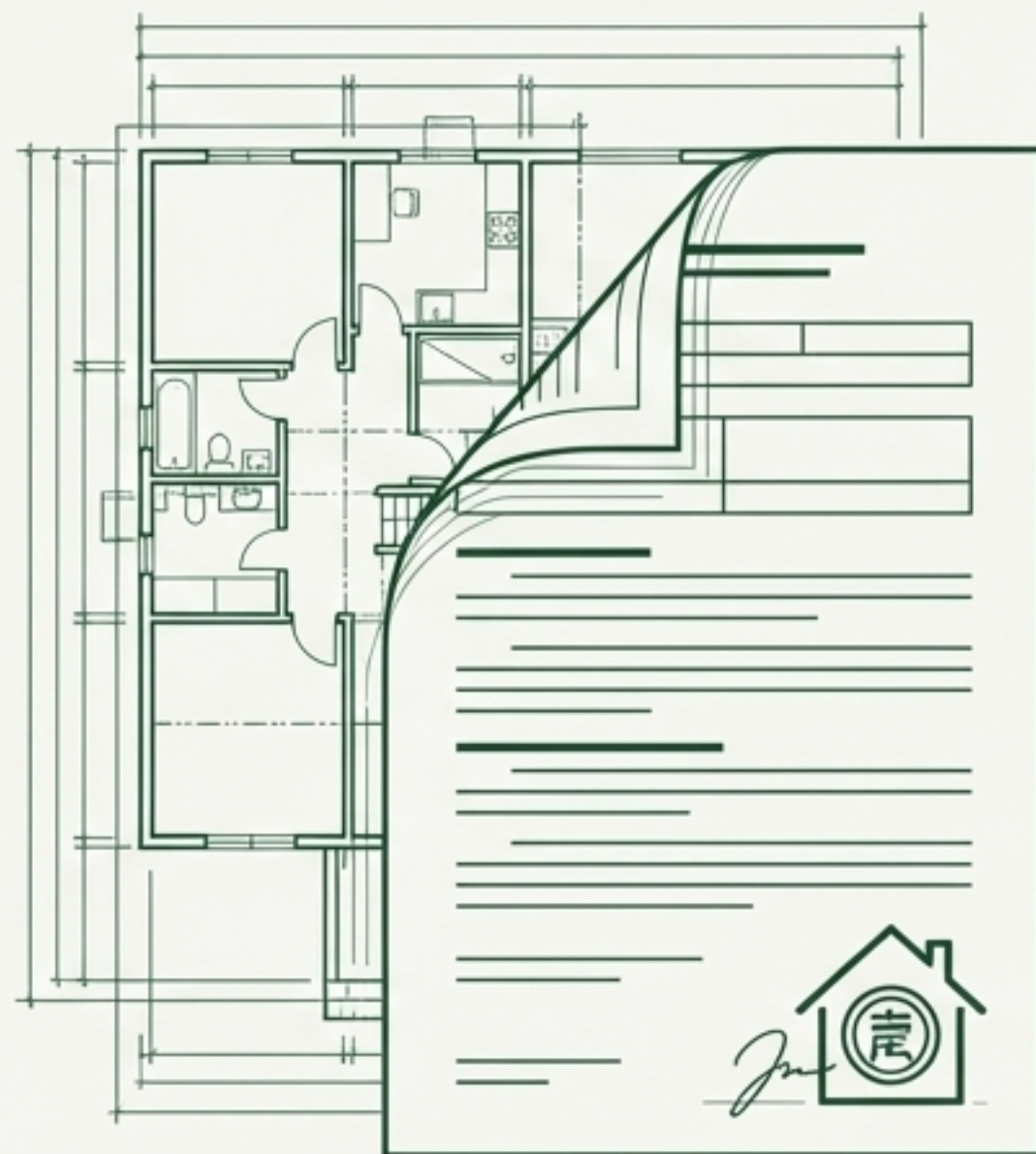
“가족관계의 등록 등에 관한 법률”에 따른 신고.

실질적 요건 (Substantive Requirements)

- 당사자 간 혼인 의사의 합치.
- 혼인 적령 (남녀 모두 만 18세).
- 미성년자의 경우 부모 등 동의.

효과 (Effects)

- 부부 공동생활 비용 공동 부담 (민법 제833조).
- 일상 가사 비용에 대한 연대 책임.



길이 나눌 때: 대한민국 양육권의 현실

현행 제도의 초점 (Focus of the Current System)

법원의 주류적 판결은 '양육의 편의성' 측면에 비중을 둬.

결과 (The Result)

부모 중 일방에게만 인정되는 '단독양육권'이 일반적.



그러나 이것이 과연 이혼한 부모와 자녀 사이의 유대관계 유지를 우선적으로 고려하는 최선의 길인가?

단독양육권이 만드는 보이지 않는 상처



1. 단독양육권 판결 (Sole Custody Ruling)



2. 감정적 왜곡 (Emotional Distortion)

양육권자는 자녀에게 비양육친에 대한 원망과 인격적 폄하를 통해 심리와 감정을 왜곡시키는 경우가 비일비재함.



3. 죄책감 형성 (Formation of Guilt)

아이는 비양육친을 만나는 것을 죄악시하게 되고, 결국 면접교섭을 거부.



4. 권리의 형해화 (Nullification of Rights)

법원은 자녀의 거부에 대해 강제 수단이 없어, 비양육친의 면접교섭권은 사실상 무력화됨.

결론: “결국 이렇게 되면 비양육친은 법원에 의하여 양육권도 빼앗기게 된 것이고, 나아가 면접교섭권도 사실상 상실됨.”

세계적 표준으로의 전환: 독일의 사례

과거 (The Past)

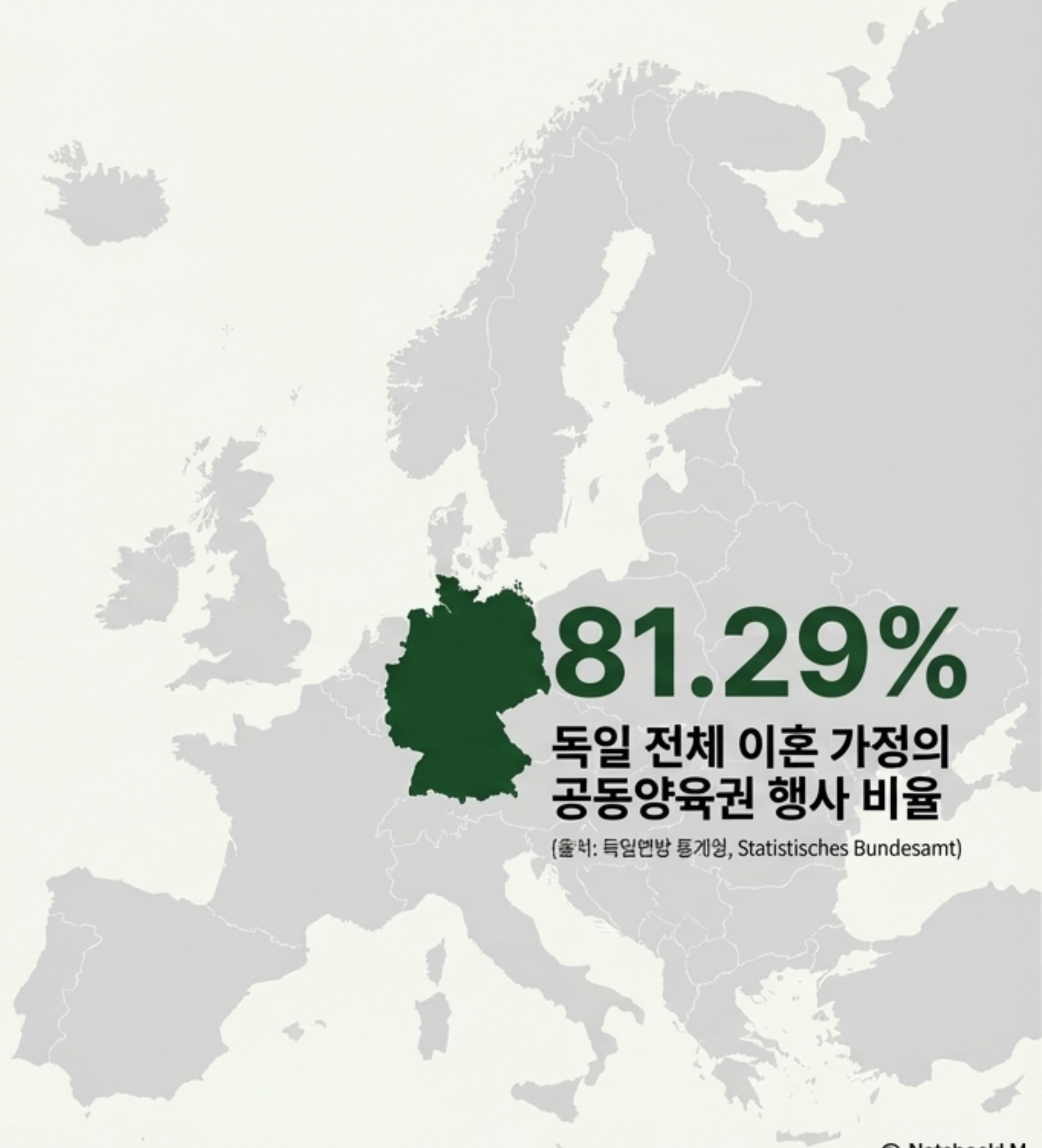
- 1979년까지 독일도 단독양육권 원칙을 따름 (구 독일 민법 제1671조).

→ 전환점 (The Turning Point)

- 1982년, 독일 연방헌법재판소가 단독양육권 규정은 부모의 친권을 침해하는 위헌이라고 판결 (BVerfGE 61, 358).

→ 현재 (The Present)

- 공동양육권이 법적 원칙으로 확립. 이혼 부모의 특별한 합의나 청구 없이도 당연히 보장됨.



공동양육권의 긍정적 파급 효과



자녀의 복리 (For the Child's Welfare)

- 이혼 부모로부터 균등한 사랑을 받으며 안정적으로 성장.
- “마치 이혼하지 않은 가정과도 견줄 수 있을 만큼” 유대관계 유지.



부모의 안정 (For the Parents' Stability)

- 양육권을 갖지 못한 부모가 겪는 우울증, 삶의 의욕상실 등 사회적 문제 해결에 도움.
- 미국 1,700쌍 조사 결과: 공동양육 시 아버지들이 아이와 약속을 잘 지키고 올바른 직장생활을 영위.



사회의 건강 (For a Healthier Society)

- 이혼 가정의 해체로 인한 사회적 비용 감소.
- 안정적 환경에서 자란 건강한 시민 양성.

헌법적 당위성: 왜 바뀌어야 하는가

단독양육권 지정 판결은 진정한 자녀의 복리를 침해하며,
헌법 정신에 위배될 소지가 있음.

자녀의 권리 침해

: 부모 모두에게 균등한 사랑을 받을 자녀의 복리를 저해.

헌법 제10조 (행복추구권)

: 안정적인 양육 환경에서 행복을 추구할 권리 침해.

헌법 제36조 (양성평등의 원칙)

: 한쪽 성별의 부모에게 양육 부담이 집중될 수 있는
기존 관행은 양성평등 원칙과도 관련.



현재의 판결은 “양육권자의 양육의 편의성과 이기적 심리에 방조하게 된다는 오해를 초래할 수 있음.”

작은 변화의 시작: 한국 법원의 새로운 시도

최근 법정 이혼에서 공동양육권에 관한 법원의 조정 및 판결 사례가 등장하고 있음.

조정 성공 사례 (Successful Mediation Case)

서울가정법원에서 맞벌이 부부에게 ‘주중에는 모, 주말에는 부’가 양육하는 조정안을 제시하여 양측이 동의.

판결 사례 (Ruling Case)

세 자녀를 모두 아동보호시설에 보낸 부부의 이혼 소송에서, 법원은 “부모로서 최소한의 도리를 행하라”며 부모 쌍방 모두에게 친권과 양육권을 인정.

과제 (The Challenge): “문제는 이러한 판결이 극소수이기에 확대되어야 함.”



부모의 불편함보다 아이의 행복이 우선입니다

- 공동양육권은 이혼을 통해 이기심을 충족한 부모들이 자녀의 복리를 위해 인내하고 감수해야 할 책무입니다.
- 자녀의 입장에서는 세상에서 둘도 없는 유일한 친부이고 친모이기에, 법원은 아이의 입장에서 양육권을 판단해야 합니다.

“이것이야말로 진정으로 자녀의 복리를 고려한 판결이며,
‘공정사회로 가는 계약법’의 정신을 실현하는 길입니다.”